

1501725-96.2021.8.26.0168

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: MARCUS FRAZÃO FROTA

Comarca: Dracena

Foro: Foro de Dracena

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 12/05/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2240274/2021 - DEL.SEC.DRACENA PLANTÃO, 20023869 - DEL.SEC.DRACENA PLANTÃO,

2370/21/622 - DEL.SEC.DRACENA PLANTÃO, 2240274 - DEL.INV.GER. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Dracena

Foro de Dracena

2ª Vara

Rua Bolívia, 137, Dracena-SP - cep 17900-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1501725-96.2021.8.26.0168 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501725-96.2021.8.26.0168

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2240274/2021 - DEL.SEC.DRACENA PLANTÃO, 20023869 - DEL.SEC.DRACENA PLANTÃO,

2370/21/622 - DEL.SEC.DRACENA PLANTÃO, 2240274 - DEL.INV.GER. DRACENA, 2370/21/622

- DEL.INV.GER. DRACENA

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

CLEITON VINICIUS DE SOUZA AMARO

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz de Direito: Dr. MARCUS FRAZÃO FROTA

Vistos.

I - CLEITON VINICIUS DE SOUZA AMARO foi denunciado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO como incurso nos artigos 33, caput, c.c artigo 40, inciso VI, e artigo 35, caput, ambos da Lei nº 11.343/2006, tudo na forma do artigo 69 do Código Penal, porque teria, no dia 02 de setembro de 2021, às 12h15min, na residência localizada na Rua Érico Veríssimo, 174, Jardim Brasilândia, nesta cidade e comarca de Dracena, previamente conluiado e com unidade de propósitos com o inimputável Willian Henrique de Paula, guardavam e mantinham em depósito, com intuito de venda a outrem, 07 (sete) invólucros maiores da droga Erythroxylum coca L, vulgarmente conhecida como cocaína, em sua forma solidificada, crack, com peso aproximado de 70,35g (setenta

gramas e trinta e cinco centigramas); 18 (dezoito) invólucros menores, da mesma droga, com peso aproximado de 2,13g (duas gramas e treze centigramas); um invólucro de crack, a granel, com peso de 4,93g (quatro gramas e noventa e três centigramas), além de 05 (cinco) invólucros de cocaína, com peso de 17,94g (dezessete gramas e noventa e quatro centigramas).

Consta ainda que CLEITON VINICIUS DE SOUZA AMARO, nas mesmas circunstâncias de tempo e local, se associou ao inimputável Wilian Henrique de Paula para o fim de praticar, reiteradamente ou não, o crime de tráfico ilícito de drogas.

Consta, por fim, que já na sede da Delegacia Seccional de Dracena CLEITON VINICIUS DE SOUZA AMARO, deteriorou coisa alheia pertencente ao patrimônio público do Estado de São Paulo, consistindo no braço de apoio de uma cadeira existente no local, protestando pela posterior juntada do laudo de exame pericial.

Auto de Prisão em Flagrante: (fls.6/8), Boletim de Ocorrência: (fls.31/35), Auto de Exibição/Apreensão: (fls.36/37), Fotos referentes ao Auto de Exibição/Apreensão: (fls.38/41), Laudo Pericial: (fls.46/50, 51/55, 56/60, 61/65, 162/167, 173/175, 176/178, 179/181, 182/184), Laudo do IML: (fls.80, 81, 140/141), Avaliação Indireta: (fls.146), Relatório Final: (fls.148/157), Laudo IC Objeto: (fls.168/172, 207/249).

Em audiência de custódia a douda defesa apresentou manifestações às fls.97/102, tendo o douto Promotor de Justiça apresentou manifestações às fls.104/107 e por fim, o douto magistrado manifestou-se às fls. 108/118 convertendo a prisão em flagrante para prisão preventiva.

Mandado de Prisão: (fls.121/123), Mandado de Prisão Cumprido: (fls.130/132).

A denúncia foi recebida às fls.266/271 na data de 06 de dezembro de 2021, O réu foi devidamente citado a apresentar resposta contra a acusação, o que fez as fls.258/265.

Convênio Defensoria/OAB: (fls.96).

Foi designada audiência, sendo que foram ouvidas duas testemunhas, assim como o réu foi interrogado, tudo gravado pelo sistema de mídia audiovisual.

Encerrada a instrução, as partes apresentaram alegações finais.

O Ministério Público apresentou alegações finais escritas às fls. 337/350 pugnando a procedência parcial da ação penal, eis que quanto ao crime descrito no artigo 35, da Lei de Drogas, não se reuniu provas suficientes a respeito da associação precedente aos fatos em questão, assim o non liquet. Pleiteou que quanto aos artigos 33 e 40, IV da Lei de Drogas e 163, parágrafo único, II do CP, tanto a materialidade quanto a autoria restaram comprovadas. Requereu que o cumprimento de pena deverá ser o fechado, eis que o acusado ostenta maus antecedentes, bem como é reincidente em crime específico. Rogou que na terceira fase da dosimetria, fosse considera a causa de aumento de pena prevista no artigo 40, VI da mesma lei, eis que o réu instigava a mercancia ilícita ao seu comparsa menor de idade. Pugnou que o réu não preenche os requisitos necessários inscrita no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, pois, além de reincidente, causa obstativa de natureza objetiva, os elementos carreados aos autos demonstram que o réu se dedicava a atividades criminosas, fazendo do comércio espúrio de drogas o seu meio de vida.

A Defesa do réu apresentou alegações finais escritas às fls.354/359 pleiteando a absolvição pela ausência de provas de que este concorreu para a prática do crime, bem como por não existir prova suficiente para a condenação, com fulcro no artigo 386, V e VII do CPP. Requereu subsidiariamente que a pena seja aplicada no mínimo legal, bem como o réu possa apelar em liberdade nos termos do artigo 283 do CPP.

Folha de Antecedentes: (fls.87/95, 284/293), Certidões/Antecedentes: (fls.84/86).

É o breve relato.

II – FUNDAMENTO E DECIDO.

A ação penal é PARCIALMENTE PROCEDENTE.

A materialidade dos fatos restou evidenciada quanto aos crimes descritos no artigo 33, caput, c.c artigo 40, ambos da Lei nº 11.343/2006 c.C 69 e 163 parágrafo único, III ambos do código penal, pelo Auto de Prisão em Flagrante às fls.6/8, Boletim de Ocorrência às fls.31/35, Auto de Exibição/Apreensão às fls.36/37, Fotos referentes ao Auto de Exibição/Apreensão às fls.38/41, Laudo Pericial às fls.46/50, 51/55, 56/60, 61/65, 162/167, 173/175, 176/178, 179/181, 182/184, Laudo do IML às fls.80,

81, 140/141, Avaliação Indireta às fls.146, Relatório Final às fls.148/157, Laudo IC Objeto às fls.168/172, 207/249, bem como pela prova oral colhida nos autos. Do mesmo modo, a autoria é indubitável.

Passo a descrever as oitivas colhidas tanto em solo administrativo quanto em juízo. A testemunha MARCELO RODRIGO LIMA JULIO em solo policial asseverou que é policial militar e no dia dos fatos, por volta das 11h50min, estava de serviço quando então receberam uma denúncia via COPOM dando conta de que 03 indivíduos, dizendo que seus nomes seriam "Elton", "Willian", que tinham saído da Fundação CASA há uns 03 ou 04 meses, sendo que "Cleiton", estariam na calçada, fazendo o comércio de drogas. Informa que a denúncia recebida pelo COPOM ainda transmitiu as características físicas de "Cleiton", como sendo de cabelo carapinha, pintado de amarelo, bem como dizia que a drogas ficava escondida nas lajetas, no quintal da casa indicada. Disse que então dirigiram-se até o local e ali sendo avistaram somente 2 pessoas na calçada da residência indicada. Esclarece o depoente e seu colega de farda que já conheciam os "denunciados" de ocorrências anteriores, também com envolvimento com drogas, sendo então, que já avistaram um dos indivíduos seria o menor "Willian" e o outro indivíduo seria o maior "Cleiton". Esclarece que ao avistarem a viatura policial, Willian adentrou primeiro para o quintal da casa, sendo logo em seguida adentrou "Cleiton". O depoente em face às fundadas suspeitas, também adentrou no quintal quando então avistou Willian jogando um involucro preto em uma varanda da casa, continuando seu percurso para o fundo da residência. Ato contínuo, Cleiton também fez o mesmo trajeto, quando então disse para seu colega CB Sartori ir pela lateral da casa a fim de verificar se tais indivíduos poderiam fugir. Assevera que então pegou o involucro preto que havia sido dispensado por Willian e constatou que seriam 7 involucros grandes, de substância petrificada, análoga ao entorpecente crack. Nisso, Willian retornou dos fundos da casa e então, como ele estava com a perna operada, não conseguiria fugir, tendo pedido para ele sentar e aguardar na frente da casa. Ratifica que Cleiton retornou dos fundos da casa e então foi abordado pelo depoente, tendo localizado no bolso esquerdo da bermuda uma nota de R\$ 20,00 e seu aparelho de telefone celular. Neste interim, o CB Sartori retornou e adentrou no interior do quintal da residência e veio a algemar Cleiton, visto ter dito que "o viu dispensar algo para o quintal de uma casa lateral a qual está desabitada" (sic). Informa que solicitaram apoio e colocaram ambos no compartimento da viatura policial. Perguntaram a cunhada de Willian, que estava no local, onde seria o quarto do mesmo, tendo ela indicado. Disse que em buscas no interior do cômodo, o CB Sartori localizou em cima do guarda roupas, um tubete de chocolate contendo em seu interior 18 (dezoito) involucros de substancia amarelada ao entorpecente "crack". Disse que foram então para os fundos da casa e visualizaram onde estavam os involucros que o CB Sartori havia avistado Cleiton jogar, sendo que passaram pelo arame farpado que divisa as propriedades e pegaram os involucros, constatando então que se tratava de 1 involucro com substância esfarelada, a granel, análoga ao entorpecente crack, e no outro involucro haviam 05 porções de substância esbranquiçada análoga a cocaína. Esclarece que o menor assumiu a propriedade dos entorpecentes que havia jogado na varanda, tratando-se de 7 involucros de crack, e também dos 18 involucros encontrado em cima do seu guarda roupa. O menor disse que vendia cada um dos 07 involucros maiores de "crack" por R\$ 200,00 a R\$ 300,00 cada, sendo que os involucros menores eram vendidos por R\$ 10,00 cada. Por seu turno, o acusado Cleiton negou ter jogado os involucros bem como que seria proprietário dos mesmos. Então, diante dos fatos, o depoente deu voz de prisão em flagrante aos envolvidos, sendo ambos conduzidos até este Plantão Policial. Já neste plantão, a genitora de Willian disse que Cleiton já havia apanhado do irmão mais velho de Willian, pois ficava aliciando-o para que vendesse entorpecentes. Chegando neste Plantão, Cleiton foi algemado no braço de uma cadeira ao passo que o menor não foi algemado, visto que não oferecia risco de fuga. Em dado momento, enquanto aguardavam para apresentar a ocorrência, verificaram que Cleiton haviam quebrado o braço da cadeira onde estava algemado e teria fugido pela porta da frente do Plantão Policial, com o braço da cadeira algemado em uma de suas mãos. Iniciaram uma perseguição e então o depoente correu tentando alcançar Cleiton ao passo que o CB Sartori foi com a viatura policial no mesmo sentido. Que viu que

quando Cleiton pulou um barranco de mais de 5 metros, tendo ido em seu encalço e, em seguida pegou a linha do trem sentido ao campo do Jardim Santa Clara. Conseguiram alcançá-lo e detê-lo, sendo o mesmo contido e algemado. Na ocasião Cleiton esboçou reação tendo sido necessário o uso de força física moderada para contê-lo, ocasião em que ele machucou-se no supercílio. Socorreram Cleiton até o Pronto Socorro local onde foi feito o atendimento e sutura no supercílio, sendo que em seguida trouxeram-no até o Plantão. Afirma que nem o depoente e nem seu colega CB Sartori, em nenhum momento agrediram o ora autuado Cleiton. (fls.9/10) JÁ SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO corroborou com o que foi dito em solo policial e acrescentou que o réu não apresentava características de ser usuário contumaz de drogas. Disse que a quantidade de droga apreendida é considerada alta, onde cada pedra de crack era avaliada em R\$ 300,00 e a cocaína em R\$ 50,00 cada, cumulando o montante estimado de R\$10.000,00 de ilícitos.

A testemunha JOAO CARLOS PAVIM SARTORI em solo policial asseverou que Exerce as funções de policial militar e no dia dos fatos e no dia dos fatos, por volta das 11h50min, receberam uma denúncia via COPOM dando conta de que 03 indivíduos, dizendo que seus nomes seriam "Elton", "Willian", que tinha saído da Fundação CASA há uns 03 ou 4 meses e "Cleiton", estariam na calçada, fazendo o comércio de drogas. Esclarece que ainda na denúncia recebida pelo COPOM transmitiu as características físicas de "Cleiton", como sendo de cabelo carapinha, pintado de amarelo, bem como dizia que a drogas ficavam escondida nas lajotas, no quintal da casa indicada. Imediatamente foram até o local e ali sendo avistaram somente 2 pessoas na calçada da residência indicada. O depoente e seu colega de farda já conheciam os "denunciados" de ocorrências anteriores, também com envolvimento com drogas, sendo então, que já avistaram que um dos indivíduos seria o menor "Willian" e o outro indivíduo seria o maior "Cleiton". Quando avistaram a viatura policial, Willian adentrou primeiro para o quintal da casa, sendo que logo em seguida adentrou "Cleiton". O CB Lima Julio acompanhou os denunciados, face às fundadas suspeitas, ao passo que o depoente foi pelo lado de fora da casa, pela lateral, visando evitar eventual fuga. Avistou, por cima do muro da própria casa, quando o indiciado Cleiton jogou uma sacola verde para o quintal vizinho, tratando-se de uma casa desabitada. Afirma que antes de ir pela lateral da casa, avistou do portão o menor Willian jogando um invólucro preto numa varanda da casa. Como os indivíduos não fugiram e retornaram para frente da casa, o depoente ali adentrou no quintal e algemou Cleiton, tendo em vista as suspeitas de que teria jogado a droga para o quintal vizinho. Tomou conhecimento que ao realizar buscas em Cleiton o CB Lima Júlio localizou R\$ 20,00 em dinheiro e seu aparelho de telefone celular. Ainda, tomou conhecimento de que no interior do invólucro preto dispensado pelo menor Willian na varanda, seriam 7 invólucros grandes, de substância petrificada, análoga ao entorpecente crack. Solicitaram apoio e colocaram ambos no compartimento da viatura policial. Perguntaram a cunhada de Willian, que estava no local, onde seria o quarto do mesmo, tendo ela indicado. Efetuaram buscas no interior do cômodo, e o depoente localizou em cima do guarda roupas, um tubete de chocolate contendo em seu interior 18 (dezoito) invólucros contendo substância amarelada análoga ao entorpecente "crack". Foram então para os fundos da casa e visualizaram onde estavam os invólucros de cor verde que o depoente havia avistado Cleiton jogar para o imóvel vizinho, sendo que passaram pelo arame farpado que divisa as propriedades e pegaram os invólucros, constatando então que se tratava de 1 invólucro com substância esfarelada, a granel, análoga ao entorpecente crack, e no outro invólucro haviam 05 porções de substância esbranquiçada análoga a cocaína. O menor assumiu a propriedade dos entorpecentes que havia jogado na varanda, tratando-se de 7 invólucros de crack, e também dos 18 invólucros encontrado em cima do seu guarda roupa. O menor disse que vendia cada um dos 07 invólucros maiores de "crack" por R\$ 200,00 a R\$ 300,00 cada, sendo que os invólucros menores eram vendidos por R\$ 10,00 cada. Por seu turno, o acusado Cleiton negou ter jogado os invólucros bem como que seria proprietário dos mesmos. Face ao ocorrido foi dada voz de prisão/apreensão, sendo os envolvidos conduzidos até este Plantão Policial. Já neste plantão, ouviu a genitora de Willian dizer que Cleiton já havia apanhado do irmão mais velho de Willian, pois ficava aliciando-o para que vendesse entorpecentes. Chegando neste

Plantão, Cleiton foi algemado no braço de uma cadeira ao passo que o menor não foi algemado, visto que não oferecia risco de fuga, pois andava de muletas. Em dado momento, enquanto aguardavam para apresentar a ocorrência, verificaram que Cleiton haviam quebrado o braço da cadeira onde estava algemado e teria fugido pela porta da frente do Plantão Policial, com o braço da cadeira algemado em uma de suas mãos. Iniciaram uma perseguição e então o CB Lima Júlio correu tentando alcançar Cleiton ao passo que o depoente foi com a viatura policial no mesmo sentido. Que viu que Cleiton pulou um barranco de mais de 5 metros, tendo o CB Lima Júlio ido em seu encalço e, em seguida pegou a linha do trem sentido ao campo do Jardim Santa Clara. Conseguiram alcança-lo e detê-lo, sendo o mesmo contido e algemado. Na ocasião Cleiton esboçou reação tendo sido necessário o uso de força física moderada para contê-lo, ocasião em que ele machucou-se no supercílio. Socorreram Cleiton até o Pronto Socorro local onde foi feito o atendimento e a sutura no supercílio, sendo que em seguida trouxeram-no até o Plantão. Afirma que nem o depoente e nem seu colega CB Lima Júlio, em nenhum momento agrediram o ora autuado Cleiton. (fls.11/12) JÁ SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO corroborou com o que foi dito em solo policial e acrescentou que a quantidade encontra é considerada alta, sedo que as 70 gramas apreendidas poderiam ser subdivididas em 700 pedras de crack. Disse que tanto o réu como Willian não apresentava nenhuma característica de serem usuários contumaz de drogas.

O réu CLEITON VINICIUS DE SOUZA AMARO interrogado em solo policial asseverou que não deseja comunicar ninguém acerca de sua prisão, dizendo que "todo mundo já tá sabendo" (sic). Disse que quanto aos fatos, alega que foi jogar baralho na casa do menor Willian, sendo que quando estavam entrando na residência a Polícia Militar ali chegou dizendo que iriam entrar. Assevera que no local a PM achou drogas tendo Willian assumido à autoria. Informa que os Policiais Militares lhe disseram que iriam trazê-lo como testemunha, sendo que ambos foram colocados no compartimento da viatura, todavia, os policiais militares adentraram novamente no interior da residência e retornaram com mais drogas, tendo Willian assumido que toda a droga achada no local seria de sua propriedade, entretanto, os policiais militares lhe disseram: "essa droga vai ser sua maior". Falou que quando chegaram ao Plantão Policial foi então algemado no braço de uma cadeira e então achou por bem fugir, visto que acreditava que iria ficar preso e, então quebrou o braço da cadeira e fugiu do Plantão. Ratifica que foi perseguido pelos policiais militares que conseguiram detê-lo nas proximidades do campo do Jardim Santa Clara. Em seguida foi conduzido até o Pronto Socorro, retornando após para este Plantão. Disse que apresenta lesão no supercílio esquerdo, o qual foi causado pelos policiais militares, alegando que foi agredido por ambos os policiais militares. Acrescenta que quanto a quantia de R\$ 20,00, alega que é fruto de seu trabalho, sendo que trabalha de servente de pedreiro para um tal "João Carlos", que mora no centro de Dracena, ganhando R\$ 90,00 por dia, mas que faz 1 semana que não trabalha e está de folga. Já ficou preso pela prática de tráfico de drogas, sendo que saiu da cadeia há aproximadamente 6 meses. Autoriza a devassa de dados e dos arquivos de seu telefone celular ora apreendido. (fls.14/15) JÁ SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO ratificou que no dia anterior aos fatos teria consumido uma alta quantidade de entorpecentes, como crack e cocaína, deste modo acabou ficando "varado" (sic) no período noturno, tendo ido então até a praça. Disse que sua avó teria dado o montante de R\$ 20,00 como presente e como estava com vontade de comprar foi até a casa de Willian. Assevera que foi informado por Willian que a droga ainda iria chegar então o interrogando teria ido até a praça para aguardar. Informa que pouco tempo depois Willian chamou novamente o interrogando, a qual teria ido até sua residência e ao adentar os policiais chegaram e o abordaram. Falou que Willian saiu correndo e o interrogando ficou parado, eis que como não tinha pegado a droga ainda não tinha a esconder. Esclarece que Willian em sua fuga jogou às drogas para todo lado, sendo que o interrogado foi algemado pelos policiais. Ratifica que já teve problemas com droga, porém o Willian confessou que a droga era de sua autoria. Disse que estava sob o efeito do entorpecente quando quebrou a cadeira para se evadir do local. Alega que os policiais o bateram cortando-o sua sobancelha. Falo que foi levado até o Pronto Socorro para que pudesse ser suturado. Acrescenta que

os policiais disseram que o acusado assumiria toda a autoria dos entorpecentes. Disse que está contando a verdade e a versão apresentada em solo policial é inverídica. Falou que já teve condenação de tráfico, onde trabalhava captando clientes e troca de entorpecentes.

O conjunto probatório se mostrou parcialmente suficiente a ensejar o édito condenatório, razão pela qual a condenação parcial é medida que se impõe. Inicialmente, em não havendo preliminares a serem enfrentadas e presentes as condições para o regular exercício da ação penal, bem como os pressupostos de constituição e desenvolvimento válido do processo, passo a examinar diretamente o mérito da imputação.

Trata-se de ação penal pública incondicionada, objetivando-se apurar a responsabilidade criminal dos acusados pela prática dos delitos tipificado no artigo 33, caput, c.c artigo 40, inciso V, todos da Lei nº 11.343/2006, c.c. os artigos 163, parágrafo único, III e 69 ambos do Código Penal.

De proêmio, observo que, apesar de descrita adequadamente na preambular acusatória, o crime exposto no artigo 163, parágrafo único, III do código penal não foi capitulada ao fato típico imputado ao réu pelo Ministério Público, razão pela qual aplico a emendatio libelli para reconhecê-la na forma do artigo 383 do Código de Processo Penal. Nesse sentido, dispõe o referido dispositivo:

Art. 383. O juiz, sem modificar a descrição do fato contida na denúncia ou queixa, poderá atribuir-lhe definição jurídica diversa, ainda que, em consequência, tenha de aplicar pena mais grave.

Com efeito, o réu ao se evadir do local quebrou o braço da cadeira que estava algemado, danificando patrimônio público, razão pela qual incide a capitulação do artigo 163, parágrafo único, III do código penal.

Nesse passo, verifico não ter razão a desrespeito ao contraditório pela omissão da denúncia quanto à capitulação do referido crime, eis que, apesar de não constar do enquadramento normativo da acusação, o referido crime foi narrado na preambular acusatório (conforme trecho da denúncia às fls.3 "Por fim, já na sede da Delegacia de Polícia, o DENUNCIADO, que estava algemado junto ao braço de apoio de uma cadeira, conseguiu quebra-lo, danificando-a, fugindo do local. Perseguido, foi alcançado e novamente detido, restando, contudo, dano ao patrimônio público, cujo valor será oportunamente informado."), em nada enfraquecendo o contraditório e a ampla defesa.

Ademais, a própria defesa, se quer mencionou a capitulação descrita ao artigo supracitado, evidenciando a inexistência de prejuízo, pois teve a oportunidade de se defender com base na denúncia, tanto em sede de defesa prévia quanto em sede de alegações finais. Aliás, conforme o escólio do ilustre Renato Brasileiro (Manual de processo penal, 2019, p. 1597):

É majoritário o entendimento no sentido de que, na emendatio libelli, não há necessidade de se abrir vista às partes para que possam se manifestar acerca da nova classificação do fato delituoso. A justificativa para tanto é a de que, em sede processual penal, o acusado defende-se dos fatos que lhe são imputados e não da capitulação (princípio da consubstanciamento). Assim, como não há alteração da imputação na emendatio libelli, mas mera correção de classificação mal formulada, acusado e defensor já teriam tido a oportunidade de oferecer resistência quanto à pretensão acusatória.

No mesmo sentido caminha a jurisprudência pátria, senão vejamos:

HABEAS CORPUS. CRIME DE DESOBEDIÊNCIA (ARTIGO 163 DO CPM). ALEGAÇÃO DE FALTA DE CORRELAÇÃO ENTRE OS FATOS DESCRITOS DA DENÚNCIA E OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. NULIDADE NÃO CARACTERIZADA. ORDEM DENEGADA. 1. No sistema processual pátrio, o agente se defende dos fatos a ele atribuídos e não da sua capitulação jurídica. Nulidade não caracterizada. Ordem denegada. 2. No sistema processual pátrio, o agente se defende dos fatos a ele atribuídos e não da capitulação jurídica. 3. O paciente foi denunciado por ter desobedecido ordem de superior hierárquico. Os fatos foram descritos na inicial, de forma a permitir o exercício da ampla defesa. 4. Falta de correlação entre a denúncia e os fundamentos da r. sentença não caracterizada. 5. Ordem denegada.

(STJ - HC: 146367 MG 2009/0172183-0, Relator: Ministro CELSO LIMONGI (DESEMBARGADOR

CONVOCADO DO TJ/SP), Data de Julgamento: 18/03/2010, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/04/2010)

Dos fatos narrados, pelo o que se extrai o réu em concurso de pessoas com o menor de 18 (dezoito) anos realizavam a mercancia ilícita de entorpecentes no local e circunstancias narradas na denúncia conforme demonstra a quantidade e variedade de entorpecentes encontradas.

Dessarte o crime de tráfico de entorpecentes é tipo misto alternativo, possuindo diversos núcleos, sendo certo que basta que o agente pratique um desses verbos nucleares para que incida em suas penas, o que no caso em comento se incidiu em "guardar", "trazer consigo" e "ter em depósito".

Faz-se importante consignar que é irrelevante não terem o réu e o menor sido encontrados no ato do comércio, eis que o tipo múltiplo do artigo 33 da Lei nº 11.343/06 relaciona diversas condutas, dentre elas a de "guardar", "trazer consigo" e "ter em depósito" a substância ilícita.

Ressalte-se que em que pese os policiais terem narrado tanto em solo policial quanto em juízo ratificando que o menor Willian teria assumido toda autoria quanto à posse dos entorpecentes, o réu foi visto pelos policiais no mesmo tempo e local descartando uma sacola verde em casa vizinha contendo 01 invólucro com substância esfarelada, a granel, análoga ao entorpecente crack, e no outro invólucro haviam 05 porções de substância esbranquiçada análoga a cocaína, quantidade e variedade de drogas acima do ordinário para um suposto usuário. Vejá-se que tanto o réu como o adolescente portavam sacolas contendo drogas, e tão logo avistaram os policiais tentaram empreender fuga e dispensar as sacolas.

É forçoso convir à versão defensiva que não é verossímil e contrasta com as demais provas coligidas. Aliás, diga-se, é incongruente que um adolescente traficante deixasse um suposto usuário contumaz, maior de idade, ficar na posse livre de entorpecentes destinados a ilícita mercancia no interior da residência onde ocorria essa comercialização. Até mesmo pra evitar despertar suspeitas, pontos onde vendem drogas não são dados a permitir que usuários ali permaneçam e consumam drogas. Ademais, como foi trazido a lumem pelos policiais o réu não apresentava nenhuma característica de usuário contumaz de crack, como vestes sujas, pouco asseio ou higiene, queimadura dos dedos e gengivas, cinzas nas mãos, petrechos para o consumo do crack ou da cocaína, como cachimbos, canudos, etc. Estavam serenos e bem orientados no momento da prisão.

Em verdade se conclui que a tese defensiva é a pueril versão de que toda a droga encontrada era de propriedade exclusiva do adolescente, no afã de afastar a responsabilidade criminal que ora recai sobre o réu. Aliás, conforme relatou os policiais, a genitora do adolescente afirmou que seu filho tem sido aliciado para o tráfico de drogas por Cleiton, corroborando tal conclusão.

Nota-se que desde o início da abordagem o réu e o menor de idade ao avistarem a viatura de polícia apresentaram grande inquietude deslocando-se de forma rápida para interior da residência e jogando as sacolas com drogas para longe de si. Assim, diante fundada suspeita denotada pela fuga do adolescente e do réu logo após avistar a viatura, aliado ao fato do réu e o adolescente terem jogado sacos que dispunham em suas mãos para o interior da residência ou para o terreno vizinho, foi realizado o ingresso no domicílio, onde foram encontradas 77,41 gramas droga Erythroxylum coca L, vulgarmente conhecida como cocaína, em sua forma solidificada, crack, subdivididas em 07 (sete) invólucros maiores e 18 (dezoito) invólucros menores fracionadas a mercancia, bem como 05 (cinco) invólucros de cocaína, com peso de 17,94g (dezessete gramas e noventa e quatro centigramas).

Veja-se que quantidade de entorpecente encontrada é considerada alta, muito acima do que um mero usuário teria em sua posse, o que se restringiria apenas em pouquíssimas porções para consumo.

Destaque-se como menciona às testemunhas João e Marcelo, a quantidade de entorpecentes aprendidas seria de alta lucratividade, estimando-se que o réu faturaria o montante de R\$ 10.000,00 (dez mil reais), eis que as 77,41 gramas de crack poderiam ser divididas em aproximadamente 770 pedras menores, na razão de 10 pedras de crack para cada 1g, vendidas a R\$ 10,00 reais cada.

Diante todos os elementos probatórios colhidos nos autos, provas materiais e

testemunhais, evidenciam a ocorrência dos fatos típicos, antijurídicos e culpáveis. A materialidade do delito encontra-se plenamente corroborada nos autos pelo Auto de Prisão em Flagrante às fls.6/8, Boletim de Ocorrência às fls.31/35, Auto de Exibição/Apreensão às fls.36/37, Fotos referentes ao Auto de Exibição/Apreensão às fls.38/41, Laudo Pericial às fls.46/50, 51/55, 56/60, 61/65, 162/167, 173/175, 176/178, 179/181, 182/184, Laudo do IML às fls.80, 81, 140/141, Avaliação Indireta às fls.146, Relatório Final às fls.148/157, Laudo IC Objeto às fls.168/172, 207/249, bem como pela prova oral colhida nos autos.

Do mesmo modo a autoria é indubitável, haja vista cortejar com os fatos descritos na denúncia.

Esmiúça-se que os depoimentos dos policiais merecem a normal credibilidade dos testemunhos em geral, posto que somente reproduziram o que presenciaram, inexistindo nos autos elementos dos quais se possa extrair que possuíam a intenção de incriminar indevidamente os acusados.

Ad interim, os policiais ouvidos durante a instrução foram uníssonos em seus depoimentos o que, por consequência, traz maior certeza e verossimilhança com as demais provas coligidas aos autos.

Nesse sentido já se posicionou a jurisprudência:

“Cabe ressaltar, nesse passo, que os depoimentos prestados pelos policiais são, em essência, coerentes e harmônicos. As pequenas divergências neles apontadas pela Defesa, além de próprias da natureza da prova, são relativas a fatos secundários, não retirando a credibilidade de tais testemunhos. Assim, não se pode negar valor a tais depoimentos pelo simples fato de terem sido prestados por agentes públicos, até porque, agindo no estrito cumprimento do dever funcional, com obediência aos preceitos legais, são merecedores de toda confiança, como de resto qualquer pessoa há de merecer, até prova em contrário, inexistente nesses autos” (TJSP, Ap. nº 0012346-76.2013.8.26.0050, Rel. Des. Luis Augusto de Sampaio Arruda, 1ª Câmara Criminal Extraordinária, j. 25/06/2015).

Entretanto, em que pese estar bem demonstrada a autoria e materialidade do delito previsto no art. 33 da Lei de Drogas, melhor sorte não ocorre quanto a imputação do art. 35 da citada Lei. As provas carreadas aos autos não apresentam um vínculo associativo permanente e estável entre o réu e o adolescente, tratando-se, portanto, de concurso de agentes.

Desse modo, de rigor a absolvição do réu por ausência de provas na forma do art. 366, VII, do CPP em relação a imputação de associação para o tráfico.

No que pertence ao delito de dano qualificado, restou bem demonstrada a autoria e materialidade pelo depoimento das testemunhas, pela confissão do réu, bem como pelos laudos periciais às fls. 162/167 e 168/172 atestando o dano em uma cadeira pertencente ao patrimônio público efetuada pelo acusado.

Provadas a materialidade e a autoria delitivas, ausentes causas excludentes de antijuridicidade e dirimentes da culpabilidade, bem como inexistentes nulidades, evidenciou-se a prática, pelos réus CLEITON VINICIUS DE SOUZA AMARO, de fato típico, antijurídico e culpável previsto no artigo 33, caput c.c artigo 40, inciso VI, ambos da Lei nº 11.343/2006, c.c. os artigos 69 e 163 parágrafo único, III do Código Penal.

Passo a dosimetria da pena.

1) Quanto ao delito de tráfico de drogas, do art. 33 da Lei 11.343/06:

Na primeira fase da dosimetria da pena, considerando as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, mormente aquelas a que faz alusão ao art. 42 da Lei 11.343/06, verifico que o acusado é multi-reincidente: (1) fls. 84/85, Proc. Nº 2396-77.2013; 2) fls.84, Proc. Nº 658-49.2016; 3) fls. 84/85, Proc. Nº 2396-77.2013; 4) fls.85, Proc. Nº 8872-63.2015). Desta forma, valoro uma reincidência doravante como agravante, e as demais, ora valoro como circunstância judicial desfavorável. Assim, valoro tais circunstâncias judiciais desfavoráveis em conjunto e aumento-lhe em 1/6 a reprimenda. Fixo a pena base em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 dias-multa.

Em segunda fase, verifico que o réu é reincidente específico (cf. fls.84, Proc. Nº 658-49.2016). Desse modo, aumento-lhe a reprimenda em 1/6, fixando a pena em 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 680 dias-multa.

Na terceira e última fase, verifico a incidência da causa de aumento de pena prevista no artigo 40, VII da Lei de Drogas, eis que o acusado praticou o tráfico de drogas em concurso com adolescente. Desse modo, aumento-lhe a pena na fração de 1/3, ante a informação de que o réu incitava e aliciava o adolescente a traficar com ele, mesmo contra os apelos dos familiares desse adolescente. Pena que se aquieta em 09 (nove) anos de reclusão e 906 dias-multa.

2) Quanto ao delito de dano qualificado, previsto no art. 163, parágrafo único, inciso III do CP:

Na primeira fase da dosimetria da pena, considerando as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal e verifico que o acusado é multi-reincidente: (1) fls. 84/85, Proc. N° 2396-77.2013; 2) fls.84, Proc. N° 658-49.2016; 3) fls. 84/85, Proc. N° 2396-77.2013; 4) fls.85, Proc. N° 8872-63.2015). Desta forma, valoro uma reincidência doravante como agravante, e as demais, ora valoro como circunstância judicial desfavorável. Assim, valoro tais circunstâncias judiciais desfavoráveis em conjunto e aumento-lhe em 1/6 a reprimenda. Fixo a pena base em 07 (sete) meses de detenção e 11 dias-multa.

Em segunda fase, verifico que o réu é reincidente (cf. fls.84, Proc. N° 658-49.2016). Desse modo, aumento-lhe a reprimenda em 1/6, fixando a pena em 08 (oito) meses e 05 (cinco) dias de detenção e 12 dias-multa.

Na terceira e última fase, não há nenhuma causa de aumento ou diminuição a incidir na hipótese. Pena que se aquieta no patamar retro.

Em razão do concurso material de crime previsto no art. 69 do CP, considerando que as condutas foram realizadas em contextos temporais e de local distintos, tendo ofendido bens jurídicos diferentes entre si, somo as penas, perfazendo o montante de 09 (nove) anos de reclusão e 08 (oito) meses e 05 (cinco) dias de detenção e 918 dias-multa.

Em razão do montante de pena fixado e a multi-reincidência, tenho que o réu não faz jus à substituição da pena de privativa de liberdade por restritiva de direitos, visto que não preenchidos os pressupostos do artigo 44, I, III do Código Penal. Do mesmo modo, inviável o sursis em razão dos motivos supra apresentados, nos termos do artigo 77 do Código Penal.

Atento ao que dispõe o artigo 33, §2º, "a" c.c. o §3º, todos do Código Penal, precisamente a quantidade de pena, as circunstância judiciais desfavoráveis e a reincidência específica, fixo o REGIME DE CUMPRIMENTO INICIAL FECHADO.

Fixo a pena de multa em seu valor unitário mínimo legal.

III - Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação penal, para ABSOLVER o réu CLEITON VINICIUS DE SOUZA AMARO da imputação referente ao artigo 35 da Lei 11.343/06, na forma do art. 386, VII, do CPP e para CONDENAR:

- o réu CLEITON VINICIUS DE SOUZA AMARO, como incurso no artigo 33, caput, c.c artigo 40, inciso VI, ambos da Lei 11.343/06 e art. 163, parágrafo único, III, na forma do art. 69, ambos do Código Penal à pena privativa de liberdade de 09 (nove) anos de reclusão e 08 (oito) meses e 05 (cinco) dias de detenção e 918 dias-multa, em regime inicial FECHADO, calculado o dia-multa no valor unitário mínimo legal. Considerando presentes os requisitos e fundamentos que levaram à decretação da prisão preventiva do acusado permanecem inalterados e, atento que a necessidade da prisão cautelar foi realçada pelo decreto condenatório e regime de pena ora definidos, a fim de garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal, MANTENHO a custódia cautelar do réu, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade.

Recomende-se o réu na prisão em que se encontram.

Transitado em julgado proceda a serventia com as seguintes providências:

- a) EXPEÇA-SE, guia de execução a guia de execução e formem-se os autos de execução de pena e encaminhem-se a VEC/DEECRIM competente;
- b) OFICIE-SE ao Egrégio Tribunal Regional Eleitoral por conta da suspensão dos direitos políticos do apenado, conforme disposto no artigo 15, inciso III, da Constituição Federal, e na Súmula 09 do Tribunal Superior Eleitoral.
- c) Autorizo a destruição/incineração da(s) amostra(s) substância(s) entorpecente(s) guardada(s) para contraprova nos presentes autos. Oficie às D. Autoridades da Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes DISE de Dracena e ao Núcleo de Perícias Criminalísticas de Presidente Prudente, juntamente com a cópia do Boletim

de Ocorrência de fls.31/35 e do Auto de Exibição/Apreensão de fls. 36/37 para as providências necessárias.

d) Autorizo a destruição dos objetos descritos no Auto de Exibição/Apreensão de fls.24/25, a saber: a) 01 BRAÇO DE APOIO UMA CADEIRA, COR PRETA.

e) Tendo em vista que o artigo 91, inciso II, do Código Penal, juntamente com o artigo 63, da Lei 11.343/06, estabelece que os valores e objetos apreendidos em razão do tráfico de drogas serão perdidos em favor da União, decreto o perdimento da quantia de a) R\$ 20,00, SENDO UMA NOTA DE VINTE REAIS, LACRE Nº 0008603, em dinheiro, (cf. Auto de Exibição/Apreensão a fls.36/37) apreendidos em poder do réu em favor da União. Oficie-se ao FUNDO NACIONAL ANTIDROGA (FUNAD) e à Secretaria Nacional Antidrogas, para as providências cabíveis tudo mediante termo nos autos, do qual será encaminhado uma via este Juízo. Oficie-se à D. Autoridade Policial da DISE local.

f) Quanto aos bens apreendidos relacionados ao Auto de Exibição/Apreensão às fls.36/37, se não reclamados, levando-se em consideração que o valor dos referidos bens apreendidos são significativamente reduzidos, demonstrando-se insuficiente sequer para cobrir os custos gerados ao erário pela eventual realização de alienação por leilão, em homenagem aos princípios da razoabilidade e da dignidade da pessoa humana, que devem sempre orientar todos os atos judiciais e administrativos. É de conhecimento público que, ante a realidade socioeconômica do país, inúmeras famílias não dispõem de recursos financeiros que lhes permitam adquirir aparelhos eletrônicos aptos a acessar a rede mundial de computadores, tais como computadores ou aparelhos de smartphones ou, ainda quando possuem, os mesmos são utilizados pelo membro arrimo familiar para o desempenho de sua atividade laboral, impossibilitando a inclusão; Desta forma, Autorizo a doação de dos objetos acima descritos contidos no Auto de Exibição/Apreensão às fls.36/37, à Instituição Beneficente de Dracena, para fins estritamente de destinação a criança/adolescente ou a qualquer um que não possa arcar com a compra de referidos bens, pertencentes a família reconhecidamente hipossuficiente. Oficie-se à Instituição Beneficente de Dracena, a fim de manifestar interesse. Na hipótese de manifesta ausência de interesse da donatária retro mencionadas, fica desde já autorizada a remessa à Autoridade Policial DISE DE DRACENA para destinação (fins estritamente de exercício das respectivas atividades institucionais) ou destruição dos objetos descritos acima, mediante termo a ser juntado aos autos.

Fixo os honorários do advogado nomeado nos termos da tabela do convênio OAB/PE, se o caso. Oportunamente, expeça-se a respectiva certidão de honorários.

Oportunamente, intime-se o réu para efetuar o pagamento das multas.

Custas ex legis.

Publique-se e intimem-se, dispensado o registro (art. 72, §6º, das NSCGJ).

Dracena, 10 de maio de 2022.

JUIZ DE DIREITO TITULAR

MARCUS FRAZÃO FROTA

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA